

1500761-37.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... da Lei de Drogas, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

3. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500761-37.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2141727/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 25169562 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2141727 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUÍS HENRIQUE VERZA e outro

Vítima:

Saúde Pública e outro

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 28 dias do mês de setembro de 2022 à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MM. Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Paulo Kishi e o(a) Defensor(a), dra. Juliana Fernandes Rocha de Oliveira. Apresentados os acusados LUIS HENRIQUE VERZA E LUCAS GABRIEL DUARTE DOS SANTOS, as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Janaina Roberta Batista e Alessandro Félix da Silva Quadros; as testemunhas arroladas pela defesa do réu Luis: Anna Beatriz Evangelista, Cleiton César Ribeiro Rodrigues e Ana Cláudia Simões; as testemunhas arroladas pela defesa do réu Lucas: Alexandre José de Arruda, Denis William de Faria Brito.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista dos acusados com sua defensora, em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito aos acusados a observação determinada no artigo

186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos os depoimentos das testemunhas comuns (Janaína e Alessandro), da defesa (Anna Beatriz e, Alexandre), pelo sistema virtual e, em seguida, interrogados os réus Luis Henrique e Lucas).

Pela defensora dos réus foi dito que desiste da oitiva das testemunhas Ana Cláudia Simões, Denis Willian de Faria Brito e Cleiton César Ribeiro Rodrigues.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Homologo a desistência da Defesa em relação às testemunhas Ana Cláudia Simões, Denis Willian de Faria Brito e Cleiton César Ribeiro Rodrigues.

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, LUCAS GABRIEL DUARTE DOS SANTOS e LUÍS HENRIQUE VERZA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 porque, no dia 24 de maio de 2022, por volta de 22h30, na rua da Garça, n. 332, bairro Jardim Itapuã, nesta cidade e comarca de Piracicaba, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, traziam consigo 113 (cento e treze) "eppendorfs" de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Outrossim porque, LUCAS GABRIEL DUARTE DOS SANTOS, no período compreendido entre os dias 04 de março de 2022 e 24 de maio de 2022, nesta cidade e comarca, recebeu ou adquiriu, em proveito próprio, o aparelho celular Motorola, IMEI 35161674128752, avaliado em R\$ 1.500,00, que sabia ser produto de crime, pertencente a Zildete Batista dos Santos Ganeo.

A denúncia foi recebida a fls. 138/139. Os réus foram devidamente citados (fls. 154/155 e 156) e apresentaram defesa prévia (fls. 160/163). Na instrução os réus foram interrogados e foram ouvidas as testemunhas arroladas.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelos boletins de ocorrência (fls. 09/13 e 36/37), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), fotografias (fls. 34/35) e laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 177/179).

A autoria dos crimes descritos na denúncia restou comprovada.

Segundo se apurou, policiais militares patrulhavam pelo local, quando avistaram e suspeitaram dos denunciados que, ao perceberem a aproximação da viatura, evadiram-se em direção a um estabelecimento comercial, razão pela qual foram perseguidos.

Durante a perseguição, os denunciados dispensaram uma bolsa preta que traziam consigo e lançaram-na em cima de uma laje no fundo do imóvel supramencionado.

Feita abordagem de praxe, em poder do denunciado LUÍS HENRIQUE nada de ilícito foi encontrado. Por sua vez, em poder do denunciado LUCAS foi localizado um aparelho celular, produto de furto, o qual admitiu ter adquirido, porém nada esclareceu sobre as circunstâncias da compra.

Na bolsa dispensada foram localizadas 113 porções de cocaína e a quantia de R\$ 511,50, em notas e moedas. Instados, informalmente, confessaram "a prática do narcotráfico", mas negaram a propriedade do entorpecente.

As circunstâncias apuradas, fuga do local e apreensão de porções individualizadas e dinheiro em espécie, evidenciam que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiros pessoas.

Da mesma forma, restou comprovado que o denunciado LUCAS sabia que o aparelho celular apreendido tratava-se de produto de crime, tanto que não comprovou a aquisição lícita, não apresentou qualquer documento que justificasse a posse e não comprovou o pagamento do bem.

Nesse sentido, a policial militar Janaína Roberta Batista, confirmou o que havia dito em solo policial, oportunidade em que afirmou que "estava com seu parceiro de farda em patrulhamento de rotina quando se depararam com dois indivíduos que empreenderam fuga ao notar a presença da guarnição, adentrando no estabelecimento comercial situado no local dos fatos. Que, de imediato, foram no encalço dos suspeitos, sendo possível visualizar o momento em que um deles dispensou uma

pequena bolsa preta que trazia consigo, lançando-a em cima de uma laje existente nos fundos do imóvel. Que, dada a dinâmica dos fatos, não conseguiu visualizar com precisão qual deles dispensou a referida bolsa. Que, realizada a abordagem, nada de ilícito foi localizado com os suspeitos, identificados como LUCAS e LUIZ HENRIQUE. Que, após breve vistoria, localizaram a bolsa anteriormente dispensada pelos averiguados, constatando que em seu interior havia 113 porções supostamente de COCAÍNA e, ainda, R\$ 511,50, em notas e moedas diversas. Que, indagados separadamente, os implicados confessaram a prática do narcotráfico, porém nenhum deles assumiu a propriedade do entorpecente. Que, após consultas de praxe, apurou-se que o celular em poder de Lucas seria produto de furto, conforme registrado no B.O. nº 978-22- 2º DP Piracicaba. Que, no tocante a tal celular, Lucas afirmou que o havia adquirido, nada esclarecendo sobre as circunstâncias do negócio". Em juízo, a testemunha ratificou o que havia dito na fase policial. Viu que os réus entraram juntos no bar e jogaram a bolsa na laje. A bolsa foi localizada e nela havia droga e dinheiro. Questionados eles confirmaram que estavam na prática de tráfico de drogas e disseram que o lucro seria dividido entre os dois. Não havia outras pessoas no bar. Nos fundos também não havia outras pessoas. No local estava apenas o proprietário do bar. Viu a bolsa que continha a droga e o dinheiro sendo lançada na laje dos fundos. Viu o trajeto do lançamento. Não conhecia os réus. Foi apreendido com Lucas um aparelho celular objeto de furto. Ele não deu nenhuma justificativa.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Alessandro Félix da Silva Quadros, que ratificou o depoimento na fase policial. Em juízo, acrescentou que o local em que avistaram os réus é ponto de venda de drogas. Eles viram os policiais e correram para o interior de um bar. Não conseguiu ver qual deles jogou a bolsa que continha a droga. No local só estavam eles, ou seja, jogaram na laje do banheiro. Conversou separadamente com os réus e ambos confirmaram que estavam na prática do tráfico de drogas e o lucro seria dividido igualmente. Não havia clientes ou outras pessoas no bar. Na bolsa arremessada havia droga e dinheiro. Com Lucas foi apreendido um aparelho celular e em pesquisa constou que era objeto de furto em data anterior. Lucas alegou que havia adquirido o aparelho, mas não respondeu de quem e não deu detalhes.

Anna Beatriz Evangelista disse que é amiga íntima de Luís e também amiga de Lucas. Luís não usa drogas. Sobre Lucas desconhece.

Alexandre José de Arruda disse que conhece Lucas que mora com sua filha. Ele faz "bicos" de lavar carro. Ele tem uma filha de um ano. Nada sabe sobre os fatos.

Os réus foram interrogados no inquérito e ficaram calados (fls. 5/6 e 7/8).

Em juízo, LUCAS GABRIEL disse que chamou o corréu para ir ao bar, mas como era conhecido dos policiais de ocorrência quando menor foram abordados pelos policiais. Estava apenas com o aparelho celular, mas os policiais apresentaram uma bolsinha que não era sua. Foi abordado quando jogava sinuca. Mesmo a droga não lhe pertencendo foi preso pelos policiais. Não tem nota fiscal do aparelho apreendido. Foi adquirido de uma "pessoa desconhecida que mora lá no bairro". Não confessou que vendia drogas com o corréu. Quando era menor usava maconha. Atualmente só bebia cerveja. Nada tem contra os policiais.

O réu LUÍS HENRIQUE alegou que foi abordado com o corréu, mas não estavam correndo porque haviam acabado de chegar no bar. Sobre a bolsa apreendida não era sua, nem do corréu. Havia outras pessoas no bar. Não sabe aonde essa bolsa foi localizada. Não disse aos policiais que estava vendendo droga. Não usa drogas. Não conhecia os policiais.

Com efeito, as imputações restaram devidamente comprovadas.

Ademais, não há nada nos autos que desmereça os depoimentos dos policiais militares, os quais são esclarecedores e levam à culpabilidade do réu.

Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos policiais militares são plenamente válidos como meio de prova, se produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela.

Portanto, merecem credibilidade os depoimentos dos policiais diante da coerência e harmonia com o restante do acervo probatório, além do que, sequer possuíam motivos

para incriminá-los.

Com efeito, “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/64), de maneira que é “inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372 e, no mesmo sentido, STRTJ 68/54).

Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento do HC nº 123293/MS, publicado no dia 16/11/2009, do qual se extrai o seguinte trecho:

O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova.

Ainda nesse sentido:

PROVA - TESTEMUNHA - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - O testemunho de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como de qualquer outro testemunho - Merecem credibilidade e se de acordo ou conformidade com as demais provas, justificam um decreto condenatório - Entendimento - Precedentes - Recurso parcialmente provido. (Apelação n. 990.08.180251-1 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton de Oliveira Neves - 04/05/2010 - 8640 - Unânime). (Grifei).

Desse modo, considerada a quantidade de entorpecentes apreendida, a forma de acondicionamento da substância, e a confirmação da prova em juízo, indubitável que a droga se destinava à comercialização.

Também restou demonstrado que LUCAS GABRIEL sabia que o aparelho celular de que tinha a posse se tratava de produto de crime, tanto que não comprovou a origem lícita, não comprovou o pagamento pela aquisição e não indicou a identidade do vendedor.

Assim, comprovadas materialidade e autoria delitivas a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

As penas base poderão ser fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem valoradas para ambos os crimes.

Na terceira fase de dosimetria da pena também inexistem causas de aumento de pena.

Vale ressaltar, que, embora LUCAS GABRIEL seja tecnicamente primário, a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, não pode ser reconhecida a ele na hipótese em tela, pois registra diversas passagens por atos infracionais análogos ao delito ora imputado (fls. 52/53), bem como a quantidade da droga apreendida demonstra, nitidamente, a dedicação às atividades criminosas de forma habitual, além de não exercer atividade lícita.

Ainda que os atos infracionais não possam ser considerados para apreciação dos maus antecedentes e reincidência, nada impede que sejam considerados para demonstrar a personalidade do agente voltada para o crime e sua dedicação às atividades ilícitas.

Nesse sentido:

“PENAL.HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DEDIREITO. INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

3. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidencia a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes da Quinta Turma.

4. Concluído pelas instâncias antecedentes que o paciente se dedica ao comércio ilícito de entorpecentes, tendo em vista, além da quantidade e da variedade da droga apreendida (60,50g de maconha e 7,67g de cocaína), o fato de que ao tempo do delito em apreço, ele estava no curso de liberdade assistida pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.

5. Estabelecida a pena definitiva em 5 anos de reclusão, revela-se correta a imposição inicial do regime fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada), tendo em vista a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, conforme o art. 33, § 2º, "a", e § 3º, c.c. o art. 59, ambos do CP, e o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

6. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quantum da sanção aplicada (art. 44, I, do Código Penal). 7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 364.837/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017). GRIFO NOSSO.

Destarte, incabível a incidência do privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, para LUCAS GABRIEL, pois a personalidade do réu e a quantidade de entorpecente demonstram que ele se dedica à atividade espúria.

Por consequência, ao réu LUCAS GABRIEL deve ser vedada a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos (artigo 44 da Lei nº 11.343/06) e que, com o advento da Lei nº 11.464/07, o regime inicial para o cumprimento de pena deve ser o fechado (artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90).

Por fim, seja decretado o perdimento do valor apreendido com os acusados, consistente em R\$ 511,50 (quinhentos e onze reais e cinquenta centavos), com fulcro nos artigos 61 e 63, da Lei nº 11.343/2006.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente garantia da ordem pública, deverá ser indeferido apelo em liberdade para LUCAS GABRIEL.

Ante o exposto, requeiro a procedência da ação nos sobreditos termos.

Dada a palavra à nobre defensora dos acusados, manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, LUCAS GABRIEL E LUIZ HENRIQUE, já qualificado nos autos de processo crime que lhe move a JUSTIÇA PÚBLICA, vem respeitosamente perante a alta presença de Vossa Excelência, em cumprimento ao r despacho, apresentar: MEMORIAIS FINAIS,

1. DA DENÚNCIA

CARLOS, foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pelos seguintes fatos narrados na denúncia:

FATO : Imputa-se aos denunciados a prática do delito previsto nos artigos 33 caput da lei 11.343/06 .e ao denunciado LUCAS também o delito de receptação.O indiciado foi preso em flagrante delito, pela suposta da prática do crime descrito no artigo 33 da Lei de Tóxicos.Em Apartada síntese consta dos autos que Os averiguados foram presos em flagrante delito, porque surpreendidos mantendo sob suas responsabilidade substância entorpecente voltada à mercancia ilícita, conforme Boletim de Ocorrência e Auto de Constatação juntados aos autos. 6- Policiais Militares desta cidade, em patrulhamento de rotina, avistaram os averiguados em via pública, os quais, tão logo avistaram a aproximação da viatura, saíram imediatamente em fuga, ingressando

em estabelecimento comercial próximo. Diante daquele comportamento, os policiais saíram no encalço dos averiguados e, durante a perseguição, perceberam que um deles dispensou uma bolsa pequena, lançando-a sobre uma laje existente nos fundos do imóvel. Efetuada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os averiguados. No entanto, verificada a bolsa por eles dispensada, constataram que em seu interior havia 113 porções de cocaína e a quantia de R\$ 511,50, em notas e moedas diversas. Indagados separadamente sobre os atos, ambos os averiguados confessaram a prática da mercancia ilícita. Posteriormente, em consulta ao aparelho de telefonia celular encontrado em poder do averiguado Lucas, constatou-se que se tratava de bem proveniente de furto. O Contexto em que se deu a prisão dos averiguados, portanto, observado a quantidade e forma como embalado o entorpecente apreendido, indica, em princípio, possam eles de fato estarem envolvidos na prática de tráfico de drogas

2-DO DIREITO

2.1 DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO

Partindo-se de uma visão constitucional do processo penal brasileiro, a sistemática de apuração da ocorrência de infração penal deve sempre levar em consideração os princípios da presunção de inocência ou de não culpabilidade (artigo 5º, LVII, CF/88), o princípio do favor rei ou do in dubio pro reo e o da paridade de armas, para que se possa chegar à conclusão de que o órgão acusador é o único responsável direto pela produção de provas, ou seja, o portador do ônus de provar cabalmente a existência da infração penal e quem foi o seu autor.

É neste sentido que caminha o artigo 156 do Código de Processo Penal, in verbis: . "A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício (...)" .

Também se pode extrair essa conclusão da interpretação a contrário senso do art.

386, VI, parte final, do Código de Processo Penal, que assim preceitua:

"art. 396. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...) VI - existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1o do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

Outro não é entendimento da jurisprudência. Veja-se:

"(...)III. O Estado Democrático, que consagra o estado de inocência como garantia constitucional, faz com que, no processo penal, todo o ônus de provar a existência do crime e suas circunstâncias fique a cargo da acusação." (TJMG; APCR 6016993-92.2009.8.13.0024; Belo Horizonte; Quinta Câmara Criminal; Rel. Desig. Des. Pedro Vergara; Julg. 16/11/2010; DJEMG 07/12/2010)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DO APELADO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO - RECURSO IMPROVIDO. Há que absolver o agente quando não existem provas suficientes a lastrear um decreto condenatório, ou seja, havendo dúvida quanto à autoria há de se aplicar o princípio do "in dubio pro reo". (TJMS, ApCriminal n. 2009.022059-9, Primeira Turma Criminal, Rel. Des. Marilza Lúcia Fortes, j. em 24.11.2009)

Mas cumpre destacar que não é qualquer prova que será hábil ao fim proposto. É preciso que a prova seja judicializada, isto é, produzida perante um Juiz de Direito e sob o manto do contraditório e da ampla defesa. E mais, mister se faz que a prova seja lícita e legítima, isto é, que seja produzida com a observâncias das normas constitucionais e legais.

Portanto, a premissa básica que o julgador deve ter ao examinar a sua causa é que o órgão acusador deve buscar a verdade real, produzindo provas judiciais claras e precisas de que houve uma infração penal e quem foi o seu autor ou participe, tudo com a observância das normas legais e constitucionais, sob pena de se reconhecer a dúvida, por menor que seja, em favor do réu, conforme preconiza o artigo 386, VII, do CPP.

Feitas essas considerações, passa-se à defesa dos acusados.

O conjunto probatório formado neste caderno processual é completamente frágil e não conclusivo sobre a real participação dos mesmos no delito de tráfico de drogas que

supostamente ocorreu, haja vista que os acusados negam veemente que estavam na posse de qualquer substância entorpecente. Ao revés, as provas produzidas pela acusação são apenas indiciárias, de modo que não servem para qualquer juízo de condenação.

Como se verifica do interrogatório dos acusados, eles negam veementemente que jamais praticaram o delito descrito na inicial acusatória.

De mais a mais, o depoimento testemunhal utilizado pelo Ministério Público para tentar incriminar os acusados está em descompasso com o restante das provas, notadamente porque as únicas testemunhas que confirmam o fato narrado na inicial são os policiais que participaram da prisão, cujos depoimentos devem sempre ser visto com reserva, como bem é fundamentado pela Doutrina pátria:

"[...]é de bom senso e cautela que o magistrado dê valor relativo ao depoimento, pois a autoridade policial, naturalmente, vincula-se ao que produziu investigando o delito, podendo não ter a isenção indispensável para narrar os fatos, sem uma forte dose de interpretação.

(...)

Cabe, pois, especial atenção para a avaliação da prova e sua força como meio de prova totalmente isento. Sobre a possibilidade de se arrolar somente policiais para depor, em lugar de efetivas testemunhas, isto é, aqueles que presenciaram algo diretamente vinculado ao fato, está a crítica de Espínola Filho: "Amanhã, a polícia é chamada ao lugar onde um crime foi ou está sendo cometido. Vão três ou quatro funcionários, encontram pessoas dando notícias detalhadas dos fatos, com minúcias e históricos completos; ouvem-nas, e delas abstraem inteiramente, daí a seguir; pois resolvem constituir-se em testemunhas, reportando à autoridade policial, na delegacia, o que lhes foi contado por toda aquela gente, que não foi incomodada, nem o nome lhe sendo tomado (Código de Processo Penal brasileiro anotado.v.3,p.90)" Deste modo, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, há de ser julgada improcedente a pretensão acusatória, com fundamento no artigo 386, V, do Código de Processo Penal.

2.2 - DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Cumpramos ressaltar que os denunciados possuem residência fixa e que não exercem comércio ilícito de entorpecentes conforme afirmado na denúncia, sendo usuários de entorpecentes.

TJ-DF: Embargos Infringentes Criminais. EIR 20120111829890 (TJ-DF). Ementa: PENAL EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. FALTA DE PROVAS DA MERCANCIA. RECURSO PROVIDO. I. A apreensão de pequena quantidade de droga, bem como a ausência de investigações em curso, a demonstrar suspeita de mercancia ilícita de entorpecentes, e a falta de abordagem de suposto adquirente são indicativos de que a droga era para consumo próprio.

II. Ausente a prova inconteste do tráfico, correta a desclassificação da infração para uso próprio. Não é suficiente a probabilidade do cometimento do delito. A dúvida acerca da destinação das drogas apreendidas se revolve em favor do réu.

III. Recurso provido. Verifica-se que nos autos não há nenhuma prova capaz de incriminar o denunciado de forma concreta e inequívoca ao delito em que é acusado, pelo contrário, existem apenas presunções.

Como sabemos, no processo penal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser indiscutível e cristalina. O denunciado não é nem nunca foi traficante, conforme aduzido na denúncia.

Não há prova nos autos, de acordo com a análise dos depoimentos, do local do fato, das condições em que se desenvolveu a ação, das circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do denunciado, cheguem à certeza de que a prática do fato era realmente tráfico de drogas, razão pela qual, em caso de não absolvição, mostra-se necessária a desclassificação.

Os acusados não se dedicam a atividades criminosas e nem integram organização criminosa.

No que diz respeito ao tráfico privilegiado, o legislador não estabeleceu um critério objetivo para determinar com será feita a diminuição, que pode ser de 1/6 a 2/3.

Para NUCCI, o magistrado deve: Pautar-se pelos elementos do art. 59 do Código

Penal, com a especial atenção lançada pelo art. 42 desta Lei: “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

É lógico que há de existir o cuidado de evitar o bis in idem, ou seja, levar em conta duas vezes a mesma circunstância. As causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual.

Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário, de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como a pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição da pena (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base (a primeira etapa da aplicação da pena, conforme art. 68 do Código Penal). Presentes as atenuantes, a pena a ser cominada ao acusado deve ser a mínima legal.

3-DA RECEPÇÃO

Quanto ao réu LUCAS ainda recai a acusação de receptação.

Excelência, o mesmo trocou seu celular que tinha nota fiscal por esse celular e ainda deu um valor ao rapaz que efetuou a troca.

Ele não sabia que o celular era produto de furto.

É pacífico na jurisprudência pátria que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, tem especial relevância. Ainda assim, sua declaração deve ser avaliada em conjunto com as demais provas carreadas no processo. Prevalecendo a dúvida quanto ao fato anteriormente ocorrido com o objeto antes que chegasse à posse do acusado, impõe-se a absolvição por insuficiência do conjunto probatório.

Portanto, o delito de receptação exige que o sujeito ativo tenha conhecimento de que o objeto é produto de crime. É imprescindível que exista a certeza da origem ilícita do objeto e mais, que o sujeito ativo também tenha pleno conhecimento dessa origem ilícita.

Portanto a absolvição nesse caso é a mais lidima justiça.

4-DOS PEDIDOS

Diante o exposto requer:

I- Que seja acolhida a tese de absolvição dos denunciados, pela ausência de provas de que estes concorreram para a prática do crime, nos termos do art. 386, V do CPP e/ou Caso não seja este o entendimento, que seja absolvida por não existir prova suficiente para a condenação, com base no art. 386, VII, do CPP, ou ainda caso assim entenda, desclassificar o delito para o descrito no art. 28 da Lei 11.343/06;

II - Caso entenda pela condenação dos denunciados, o que não se espera, requer a aplicação da pena no mínimo legal, com a devida aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, analisando as circunstâncias pessoais favoráveis da denunciada (artigo 59, inciso IV, do Código Penal) e conversão em penas restritivas de direitos, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, posto que o denunciado preenche todos os requisitos.

III - Em caso de condenação, a aplicação do art. 59 da Lei 11.343/06 c/c 283 do Código de Processo Penal, somado aos princípios da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal), entendimento da prisão como ultima ratio, Lei 12.403/11 (medidas cautelares diversas da prisão), pelos efeitos negativos do cárcere, requisitos favoráveis do denunciado (primário, residência fixa, trabalho lícito), para que possa recorrer em liberdade.

IV Por fim, caso vossa excelência decida pela condenação, que reconheça a circunstância atenuante estabelecida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, de forma a ser fixada a pena no mínimo legal.

Termos em que, pede Deferimento.

Em seguida pela MM. Juíza foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

LUCAS GABRIEL DUARTE DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque entre os dias 04 de março de 2022 a 24 de maio de 2022, nesta cidade e Comarca, adquiriu, em proveito

próprio, o aparelho celular Motorola, IMEI 351616741218752, avaliado em R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que sabia ser produto de crime, pertencente a Z.B.S.G. LUCAS GABRIEL DUARTE DOS SANTOS e LUIS HENRIQUE VERZA, qualificado nos autos, também foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 combinado com o artigo 29, caput, do Código Penal, porque no dia 24 de maio de 2022, por volta de 22h30, na Rua da Garça, nº 332, bairro Jardim Itapuã, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso de agentes e unidade de designios, traziam consigo 113 eppendorfs de cocaína, destinados à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares patrulhavam pelo local, quando avistaram e suspeitaram dos réus que, ao perceberem a aproximação da viatura, evadiram-se em direção a um estabelecimento comercial, razão pela qual foram perseguidos.

Durante a perseguição, os réus dispensaram uma bolsa preta que traziam consigo e lançaram-na em cima de uma laje no fundo do imóvel supramencionado.

Feita a abordagem de praxe, em poder do réu LUIS HENRIQUE nada de ilícito foi encontrado. Por sua vez, em poder do réu LUCAS foi localizado um aparelho celular, produto de furto, o qual admitiu ter adquirido, porém, nada esclareceu sobre as circunstâncias da compra.

Na bolsa dispensada por eles foram localizadas 113 porções de cocaína e a quantia de R\$ 511,50, em notas e moedas. Instados, informalmente, eles confessaram "a prática do narcotráfico", mas negaram a propriedade do entorpecente.

As circunstâncias apuradas, fuga do local e apreensão de porções individualizadas e dinheiro em espécie, evidenciam que a droga apreendida se destinava à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

Da mesma forma, restou comprovado que o réu LUCAS sabia que o aparelho celular apreendido se tratava de produto de crime, tanto que não comprovou a aquisição lícita, não apresentou qualquer documento que justificasse a posse e não comprovou o pagamento do bem.

A denúncia foi recebida (fls. 138/139), os réus citados (fls. 153 e 156), apresentando resposta escrita, na qual requereram a rejeição da denúncia por falta de justa causa e, no mérito, alegaram inocência (fls. 160/163).

O recebimento da denúncia foi mantido, designando-se audiência (fls. 170/172).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas de acusação e 02 testemunhas de defesa, sendo os réus interrogados.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade do crime de tráfico de drogas está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, no laudo de constatação preliminar de fls. 17/19, nas fotografias de fls. 34/35, e no exame químico-toxicológico de fls. 177/179, segundo o qual foi detectada a presença de cocaína nas substâncias apreendidas.

Já a receptação tem sua materialidade criminosa calcada no auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, na fotografia de fls. 35, no boletim de ocorrência do furto de fls. 36/37, no boletim de ocorrência de entrega do objeto de fls. 119/120, bem como no auto de entrega de fls. 121.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase policial, os réus permaneceram calados (fls. 05/08).

Em Juízo, o réu Lucas afirmou que chegou do lava-rápido e chamou o cunhado Luís para irem no bar. Quando estavam indo, os policiais passaram e o abordaram, porque o reconheceram da época da adolescência. Foi abordado na mesa de bilhar, na frente do bar. Havia mais pessoas na parte de dentro do bar. Os policiais encontraram com ele o celular, que não sabia que era produto de furto. Com Luís, não havia nada. Os policiais foram aos fundos do bar, mandou que as pessoas saíssem, depois reviraram

e voltaram com uma bolsinha. A bolsinha não era dele e nem de Luís. Os policiais não revistaram ninguém, apenas eles. Pediu que não fosse preso, porque tem filha pequena para cuidar, mas mesmo assim, o policial disse que a droga era sua. Ninguém viu os policiais encontrando a bolsinha. Os policiais ficaram bastante tempo para encontrar a bolsa, enquanto o outro policial ficou conversando com ele. Quanto ao celular, estava sentado na frente de sua casa, quando um rapaz passou pela rua e lhe ofereceu o celular. Ele queria R\$ 500,00, mas lhe ofereceu um outro celular LG e mais R\$ 150,00. Ele aceitou e fizeram a negociação. Até perguntou se o celular era produto de crime, mas ele disse que não. Não conhecia essa pessoa. Não recebeu nenhum documento referente a esse celular. Perguntou ao rapaz se ele queria a nota do celular LG e ele disse que não. Não sabe onde essa pessoa mora ou onde pode ser encontrado. Não confessou aos policiais o tráfico de drogas. Não faz uso de drogas, só bebida cerveja.

E o réu Luís disse que no dia dos fatos, tinha chegado do serviço e chamou o cunhado Lucas para jogar bilhar e tomar cerveja, no bar, que fica perto de sua casa. Estavam jogando bilhar, quando os policiais os abordaram, dentro do bar, e pediram que o pessoal saísse. O pessoal saiu e os únicos que ficaram dentro do bar foram eles, o dono do bar e os policiais. Os policiais falaram que estavam correndo dos policiais, mas tinham acabado de chegar ao estabelecimento. Tinha tanta gente no bar, de forma que não sabe de quem era a bolsinha. A bolsinha não era dele ou de Lucas. Não sabe onde a bolsinha foi encontrada. Os policiais só falaram que encontraram a bolsinha quando estavam dentro do viatura. Não sabe nem se a bolsinha estava no bar. Não confessou a prática delitiva aos policiais. Não faz uso de drogas. Quanto ao celular, Lucas o trocou com um rapaz do bairro, entregando o celular mais barato dele, que tinha nota. Não houve entrega de dinheiro, apenas troca de celular. Lucas não sabia que o celular era roubado.

A negativa de autoria restou isolada nos autos. Vejamos.

A policial militar Janaina Roberta Batista narrou que estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro e passaram por um local conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram duas pessoas que, ao perceberem a aproximação da Polícia, correram e adentraram em um bar, indo para os fundos. No trajeto da fuga, não conseguiu ver a bolsa. Viram que eles arremessaram uma bolsa em uma laje do banheiro. Não soube dizer quem deles arremessou a bolsa. Na bolsa, além da droga, havia dinheiro. Eles foram abordados e, com Lucas, havia um celular que, pesquisado, constatou-se ser produto de furto anterior. Questionados sobre a droga, eles confessaram que estavam na prática do crime de tráfico e que o lucro da venda seria dividido entre eles. No fundo do bar, só havia os réus. Na frente do bar, só estava o proprietário. Conseguiu ver que a bolsa foi lançada e caindo em cima da laje. Nem precisaram procurar a bolsa, porque sabia onde ela tinha sido arremessada. Não conhecia os réus. Questionaram Lucas sobre quem lhe vendeu o celular, quanto foi o preço, no entanto, ele não quis dizer nada.

No mesmo sentido, o depoimento do também policial militar Alessandro Felix da Silva Quadros, que explicou que estavam em patrulhamento de rotina, quando passaram em local conhecido como ponto de venda de drogas, na rua, perto do bar. Ao avistar a equipe, dois indivíduos saíram correndo e entraram num bar. Entraram no bar, em seguida, e viram que os indivíduos estavam nos fundos e avistaram uma bolsa que tinha sido arremessada para a laje do banheiro desse bar. Não chegaram a ver quem é que efetuou o arremesso. Os indivíduos foram abordados e nada de ilícito foi encontrado com ele. Na bolsa que eles jogaram, encontraram drogas e dinheiro. Os indivíduos foram separados e ambos disseram que estavam no tráfico de drogas e o dinheiro seria dividido entre eles. Eles não descreveram quem tinha jogado a bolsa. Nos fundos do bar não havia mais ninguém, além dos réus. Fora os réus, na parte da frente do bar, só estava o proprietário do bar. Com o réu Lucas, havia um celular e pesquisaram pelo terminal de dados e constataram que era produto de furto anterior. Lucas informou que havia adquirido o celular, mas não disse de quem nem onde ou quanto pagou. Não conhecia os réus.

Zildete Batista dos Santos Ganéo, proprietária do celular, ouvida apenas em solo policial, alegou que deixou seu celular com o filho e foi à manicure. Quando retornou, não encontrou mais seu celular. O filho lava carros na garagem de sua

casa e estava atendendo o proprietário de uma motocicleta. Recebeu ligação da Delegacia, comunicando que seu celular tinha sido localizado. Compareceu à Delegacia com nota fiscal e caixa do aparelho, reconheceu o aparelho apreendido como sendo seu. Avalia o celular em R\$ 1.500,00 (fls. 118).

Alexandre José de Arruda contou que Lucas é pai da sua neta e Luís é filho da sua esposa. Não tem intimidade com os réus. Estava dormindo quando os réus foram abordados. Luís mora com ele. Ele trabalha de porteiro, faz pintura. Ele é solteiro e não tem filhos. Lucas também mora com ele. Ele fica no período da manhã cuidando da filha, porque a mãe vai para a escola e à tarde faz "bicos" lavando carros, para não faltar leite da filha. A filha de Lucas vai completar 01 ano. Não sabe se os réus têm envolvimento com drogas, nunca ouviu falar nada sobre isso. Lucas é um bom pai.

Anna Beatriz Evangelista comentou que é amiga íntima de Luís e pouco amiga de Lucas. Não presenciou os fatos narrados na denúncia. Conhece Luís há 02 anos, porque seu ex-marido era amigo dele. Luís trabalha de porteiro e faz "bicos" de servente, desentupidor. Ele não é casado e não tem filhos. Ele não tem envolvimento com drogas. Pelo que sabe, Lucas não tem envolvimento com drogas. Quanto ao tráfico de drogas, a primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento dos réus com a droga apreendida.

Em solo policial, os réus permaneceram calados. Em Juízo, os réus falaram que estavam no bar, jogando bilhar ou tinham acabado de chegar ao bar, quando foram abordados. Alegaram que havia várias pessoas no bar, no entanto, foram retiradas e os policiais encontraram a bolsinha com a droga, que não lhe pertencia. Negaram terem confessado a prática do crime.

Ao lado da negativa de autoria por parte dos réus, existem os depoimentos dos policiais militares, segundo os quais estavam realizando patrulhamento de rotina, quando avistaram os réus em ponto de venda de drogas. Assim que perceberem a aproximação da viatura policial, eles empregaram fuga correndo e ingressando em um estabelecimento comercial (bar). Conseguiram visualizar que os réus foram para os fundos do bar, onde não havia outros clientes, e visualizaram a pequena bolsa preta sendo arremessada para cima da laje do banheiro, nos fundos do bar, mas não conseguiram distinguir qual deles. Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os réus, no entanto, na bolsa dispensada e apreendida e foram localizadas 113 porções de cocaína e R\$ 511,50 em espécie. Indagados separadamente, ambos os réus confessaram a prática do tráfico de drogas, dizendo que iriam dividir o dinheiro proveniente da venda. Ademais, em poder do réu Lucas havia um aparelho celular fruto de furto, que ele disse ter adquirido, mas não deu outras informações sobre essa negociação.

As testemunhas de defesa não presenciaram os fatos, apenas informaram que ambos trabalham e não possuem envolvimento com drogas.

Nesse sentido, temos duas versões sobre o mesmo fato: a dos réus, que negam qualquer envolvimento com a bolsa preta onde a droga foi encontrada e a dos policiais militares, segundo os quais ambos tentaram se desvencilhar de eventual abordagem e nos fundos do bar, onde só eles estavam, visualizaram a bolsa preta com a droga sendo arremessada na laje.

Resta saber qual versão merece credibilidade.

Os policiais afirmaram que já tinha avistado os réus na via pública e que eles tentaram fugir da abordagem policial, ingressando num estabelecimento comercial. Essa situação já indica atividade ilícita por parte dos réus.

De mais a mais, o fato é que os policiais não teriam encontrado a droga na laje dos fundos do estabelecimento comercial, se não tivessem presenciado o arremesso.

De outro lado, os réus afirmaram que no bar havia vários clientes nos fundos, no entanto, nenhuma pessoa foi arrolada, nem mesmo o proprietário do bar que fica nas proximidades da residência deles.

Nesse sentido, entendo que a versão dos policiais comporta crédito e deve se sobrepor à negativa de autoria por parte dos réus.

De outro lado, embora os policiais não tenham podido distinguir quem foi que arremessou a bolsa com a droga na laje, o certo é que ambos os réus tentaram se esconder no estabelecimento comercial, o que revela que sabiam da existência da

droga em poder de um deles. Além disso, os policiais presenciaram a bolsa sendo arremessada, embora não tenham podido ver quem a arremessou, mas só nos réus estavam nos fundos do bar.

Nesse sentido, fica certo que ambos tinham envolvimento com as drogas apreendidas, caso contrário, apenas um teria tentado se furtar da abordagem policial.

Por fim, como já vem decidindo a jurisprudência, a palavra de policiais, como funcionários públicos que são, tem validade como prova, em especial quando acobertada por outros elementos de prova, como a localização de grande quantidade de porções de cocaína, na bolsa que viram ser arremessada.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DO MATERIAL PROSCRITO, CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os depoimentos dos policiais militares representam sólido componente de convencimento e, encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser invocados para justificar a condenação. Aliás, na falta de qualquer adinículo de prova, suspeitar da veracidade das declarações dos policiais, que, no cumprimento do seu dever funcional, submetem-se diariamente à situação de risco para atuar no combate à narcotraficância, é inadmissível, traduzindo-se, ainda, em postura com a qual o Poder Judiciário não pode coonestar. (STF - HC: 215166 SC 0119154-54.2022.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/06/2022).

"[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (HC 705.060/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

(...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (...) (AgRg no AREsp 1934729/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

Comprovado o envolvimento dos réus com as drogas, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprove a traficância. O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11).

No caso dos autos, os réus negaram que a droga estivesse em poder deles. As provas indicam, contudo, a destinação de consumo de terceiras pessoas. Vejamos. Inicialmente, os réus, que estavam em ponto de venda de drogas, avistaram os policiais militares e tentaram se furtar à abordagem, ingressando correndo em estabelecimento comercial e demonstrando conduta ilícita. De outra banda, um dos réus arremessou a bolsa na laje dos fundos do estabelecimento, na tentativa de evitar consequências penais.

A quantidade de droga apreendida (113 porções de cocaína) e sua forma de embalo (em microtubos) indicam que era destinada ao consumo de terceiras pessoas, porque usuários não permanecem na posse de tanta quantidade de drogas, na via pública. Além da droga, na bolsa havia dinheiro, parte dele trocado (R\$ 511,50 - fotografia a fls. 35), cuja procedência lícita não foi comprovada.

Assim, a tentativa de fuga dos réus, a quantidade de droga e sua forma de fracionamento, o dinheiro em espécie; tudo revela que a droga tinha como destino o consumo de terceiras pessoas.

A condenação, assim, é de rigor.

No que se refere à receptação, está ela comprovada, porquanto o bem foi furtado (boletim de ocorrência de fls. 36/37) e, posteriormente, localizado na posse do réu Lucas (auto de exibição e apreensão de fls. 14/15).

Resta saber se o réu Lucas tinha conhecimento da origem ilícita do aparelho celular.

O elemento subjetivo, porque interno, deve ser apreciado diante das circunstâncias objetivas e externas e conduzem à convicção de que o réu tinha conhecimento da origem espúria do aparelho celular.

Lucas